

1500086-42.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Marzola Colombini

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, com o afastamento, ainda, em relação a ambos, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

A Defesa, por sua vez, em memoriais escritos de fls. 294/299, requereu, em relação a ambos os réus, a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

3ª Vara Criminal

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12940-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500086-42.2022.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500086-42.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015147/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 22497451 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2015147 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO COSME DE OLIVEIRA NETO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Marzola Colombini

VISTOS.

ANTÔNIO COSME DE OLIVEIRA NETO e BRUNO MOGHETTI CARVALHO VILIAN foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e estão sendo processados porque, no dia 17 de janeiro de 2022, no horário e no endereço mencionados na denúncia, teriam trazido consigo drogas, consistentes em 83 porções de maconha (pesando, aproximadamente, 477 gramas) e 183 porções de crack (pesando, aproximadamente, 108 gramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar às fls. 207/212.

A denúncia foi recebida às fls. 214/216.

Citados (fls. 272 e 292), em audiência de instrução e julgamento (fls. 272), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação em comum com a Defesa, sendo, ao final, realizado o interrogatório dos acusados, conforme gravações audiovisuais constantes dos autos.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em debates orais (gravação constante dos autos), requereu a integral procedência dos pedidos acusatórios, com a consequente condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, com o afastamento, ainda, em relação a ambos, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

A Defesa, por sua vez, em memoriais escritos de fls. 294/299, requereu, em relação a ambos os réus, a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas (porte de drogas para consumo pessoal). Subsidiariamente, na hipótese de condenação dos acusados por tráfico de drogas, pleiteou a fixação das penas no mínimo legal, com o reconhecimento, para ambos, da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como a conversão da pena privativa de liberdade a eles eventualmente imposta em pena restritiva de direitos. Ainda, especificamente quanto ao corréu Bruno, requereu o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No mérito, de rigor a integral procedência dos pedidos acusatórios, para o fim de condenar os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, com o reconhecimento, no entanto, apenas com relação ao corréu Antônio, da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pelas razões abaixo mencionadas.

Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 13/14, pelas fotografias de fls. 15/16, pelos laudos de exame químico toxicológico de fls. 198/203, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, da mesma forma, restou inequívoca com relação a ambos os acusados.

O corréu Bruno Moghetti Carvalho Vilian, na fase policial (fls. 05), se manteve em silêncio.

Em juízo, contudo, confessou (parcialmente) a prática do delito, aduzindo que: possui 28 anos de idade; até alguns meses antes de ser preso, era proprietário de um estabelecimento comercial (padaria, restaurante e pizzaria); é solteiro e possui um filho; possui uma passagem criminal por porte de drogas para consumo pessoal (não foi condenado); não possui passagens pela Vara da Infância e Juventude; a acusação é verdadeira; por ocasião da abordagem, realmente estava em poder de porções de crack; não se recorda a quantidade de entorpecentes que estavam em seu poder; parte das drogas se destinava ao seu consumo pessoal e, outra parte, se destinava à comercialização; à época dos fatos, estava em situação de rua e morava no interior do barraco de madeira; está arrependido da prática do delito; havia começado recentemente a comercializar entorpecentes; acabou se envolvendo com

entorpecentes e se viciou em crack; se considera dependente químico, pois estava usando bastante crack à época dos fatos; já se internou, por três vezes, em clínica de recuperação para tratar o vício em drogas; os fatos relatados pelos guardas municipais são verdadeiros, com exceção da alegação de que Antônio confessou a prática do crime de tráfico; na verdade, as porções de maconha atribuídas ao corréu Antônio também eram de sua propriedade; nenhuma das porções de entorpecentes encontradas pelos guardas municipais tinha relação com o corréu Antônio; no momento da abordagem, o corréu Antônio não saiu correndo; Antônio entrou primeiro no barraco e se sentou, tendo entrado na sequência; ao perceber a presença dos guardas municipais, realmente tentou empreender fuga, mas acabou se entregando; confessou aos guardas municipais, por ocasião da abordagem, que parte das drogas se destinava à comercialização; as porções de maconha localizadas pelos guardas municipais estavam guardadas no interior do barraco; correu em direção a um matagal, localizado atrás do barraco em que residia; estava sob o efeito de drogas no momento da abordagem policial; Antônio também morava no barraco; Antônio trabalhava com um senhor conhecido como "Seo Zé", que trabalhava com capinagem; Antônio também é usuário de drogas; no momento da abordagem, tinha acabado de chegar ao barraco com os entorpecentes; Antônio já estava no interior do barraco quando chegou; fumava crack com o acusado Antônio à época dos fatos; Antônio utilizava o barraco há mais tempo; fazia cerca de três ou quatro meses que morava no barraco; outras pessoas não frequentavam o barraco.

O corréu Antônio Cosme de Oliveira Neto, na fase policial (fls. 06), também se manteve em silêncio.

Em juízo, todavia, negou a prática do crime, afirmando que: possui 26 anos de idade; é solteiro e possui uma filha; antes de ser preso, estava fazendo "bico" como servente de pedreiro e ajudante de jardinagem; responde a processo criminal por furto (o processo está suspenso); à época dos fatos, devido ao fato de estar em situação de rua, passou a morar no barraco onde foi abordado pelos guardas municipais; é inocente da acusação; não tem relação com as drogas que foram apreendidas pelos guardas municipais; as porções de maconha não lhe pertenciam; o relato dos guardas municipais não é verdadeiro; não confessou aos guardas municipais que estava traficando; as drogas foram encontradas no interior do barraco em que estava residindo; não sabe quem era o proprietário das porções de maconha localizadas pelos guardas municipais; não sabe o exato local em que os guardas municipais encontraram as porções de maconha; não sabia que havia entorpecentes no interior do barraco; o corréu Bruno também estava residindo no barraco; Bruno assumiu para os guardas municipais a propriedade de todos os entorpecentes que foram localizados (tanto das porções de crack quanto das porções de maconha); Bruno assumiu, inclusive, que parte dos entorpecentes se destinava à comercialização; estava morando no barraco há cerca de dois meses; não conhecia os guardas municipais anteriormente; não moravam outras pessoas no barraco; fazia menos de dois meses que Bruno também estava residindo no barraco; Bruno tinha acabado de chegar ao barraco quando foram abordados pelos guardas municipais; quando foram abordados, estava preparando o crack para consumi-lo; ao perceber a presença dos guardas municipais, Bruno saiu correndo; é usuário de crack há pouco mais de um ano; nunca ficou internado para tratamento.

A versão dos fatos apresentada pelo corréu Bruno (confissão parcial) merece ser considerada apenas em parte pelo Juízo.

Já a versão do corréu Antônio (negativa dos fatos) não merece a menor credibilidade, haja vista ter restado isolada nos autos frente ao robusto conjunto probatório produzido pela Acusação.

Isto porque o guarda civil municipal Vailson Souza Santos, em juízo, relatou que: estavam em patrulhamento, no período noturno, pelo Bairro do Caetetuba quando, ao estacionarem a viatura próxima a um barraco sobre o qual havia diversas denúncias

de tráfico de drogas (as denúncias faziam menção ao fato de o local ser utilizado por moradores de rua para a realização de tráfico de drogas), visualizaram os acusados no interior do mencionado barraco; ao perceberem a presença de viatura, os acusados saíram correndo; o seu colega de farda Luís Henrique imediatamente abordou o corréu Antônio, com o qual foram encontradas várias porções de maconha; saiu correndo no encalço do corréu Bruno, tendo este, após alguns metros de fuga, se entregado; Bruno estava em poder de um recipiente no interior do qual havia cerca de 180 pedras de crack; Bruno confessou que estava traficando no local; não conhecia os réus anteriormente; as porções de crack estavam acondicionadas num tubete, prontas para a comercialização; não encontrou quantia em dinheiro em poder de Bruno; quando visualizados, os réus estavam sozinhos no interior do barraco; não visualizaram atos de comercialização; o local em que os réus foram abordados é conhecido nos meios policiais como ponto de intenso tráfico de drogas; existe uma área de mata próxima ao local em que os réus foram avistados; seu colega de farda ingressou no barraco, mas não encontrou nada de ilícito no local; os acusados confessaram a prática do tráfico de drogas no momento da abordagem e informaram que estavam usando o barraco apenas para dormir e realizar a venda de entorpecentes; o corréu Bruno chegou a informar que tinha começado a comercializar as drogas no local há pouco tempo e que venda ocorreria durante toda a madrugada, até as 7 horas da manhã.

Por fim, nesse mesmo sentido, o guarda civil municipal Luís Henrique Cometti Leme, em juízo, narrou que: na data dos fatos, estavam em patrulhamento pela região do Bairro Caetetuba/Vila Santa Clara, local este bastante conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico de drogas, quando se aproximaram de um barraco de madeira; em seguida, estacionaram a viatura defronte a este barraco ao perceberem que havia certa movimentação de pessoas no interior dele; logo após pararem a viatura, os acusados saíram correndo; conseguiu alcançar o corréu Antônio e procedeu à abordagem dele; realizada busca pessoal, encontrou, aproximadamente, 80 porções de maconha com o corréu Antônio; o corréu Bruno correu um pouco mais do que Antônio, tendo seu colega de farda logrado êxito em abordá-lo; Bruno trazia certa quantidade de porções de crack; não se recorda de terem encontrado quantia em dinheiro em poder dos réus; não se recorda da quantidade exata de porções de crack encontradas em poder de Bruno; os acusados confessaram informalmente que estavam traficando no local; não se recorda de já ter abordado algum dos acusados em ocasião anterior; os entorpecentes estavam acondicionados em porções individualizadas, prontas para a venda; os acusados estavam sozinhos no local; os acusados colaboraram com a guarnição policial; o barraco de madeira foi revistado, mas não encontraram nada de ilícito no interior dele. Nesse contexto, dúvidas não restam acerca da caracterização do crime de tráfico de drogas imputado aos acusados, tendo em vista o firme conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, em que pese o corréu Bruno ter aduzido, em juízo, que todas as porções de entorpecentes (crack e maconha) pertenciam somente a ele, tentando, nitidamente, afastar a responsabilização criminal do corréu Antônio, é certo que as provas carreadas aos autos são firmes e robustas quanto à comprovação da autoria delitiva em relação a ambos os réus.

A par disso, saliento que os guardas municipais, tanto na fase policial quanto em juízo, apresentaram depoimentos coesos e verossímeis no sentido de que estavam em patrulhamento por local já conhecido nos meios policiais como ponto de intenso tráfico de drogas quando visualizaram os réus no interior de um barraco de madeira, tendo eles, ao perceberem a aproximação da viatura, saído correndo a fim de evitarem a abordagem policial.

Além disso, foram firmes quanto ao fato de terem localizado entorpecentes em poder de ambos os réus (relataram que Bruno estava em poder de 183 porções de crack, enquanto Antônio estava em poder de 83 porções de maconha).

Os referidos guardas municipais narraram, ainda, que os acusados confessaram informalmente que estavam traficando drogas no local da abordagem.

Nesse aspecto, cumpre ressaltar o quanto aduzido pelo guarda municipal Vailson, segundo o qual havia diversas denúncias que faziam menção ao fato de o "imóvel" (barraco de madeira) ser utilizado por moradores de rua para a realização do tráfico de drogas.

Ora, a Defesa não trouxe aos autos qualquer prova capaz de afastar ou de mitigar a credibilidade do relato dos guardas municipais, razão pela qual seus depoimentos devem ser valorados de maneira positiva por este Julgador.

Nessa linha, insta ressaltar que não há que se falar em ausência de credibilidade no relato de servidores policiais (in casu, guardas municipais), na medida em que, na condição de testemunhas, suas palavras ostentam o mesmo valor probatório que o de qualquer outra, não se podendo retirar a boa-fé pelo só fato de serem agentes de segurança. Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar, tal como ocorreu com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na verdade, o testemunho de servidores policiais merece fé até prova em contrário (RT 426/439), desde que não fique demonstrada a sua inidoneidade (RT 444/406), ou o seu propósito deliberado de incriminar falsamente o réu (RT 454/422), o que não se verificou na hipótese dos autos, até mesmo porque os guardas municipais sequer conheciam os acusados anteriormente aos fatos (conforme relatado por ambos, em juízo).

Parte da versão dos fatos apresentada pelo corréu Bruno e a integralidade da versão apresentada pelo corréu Antônio, por outro lado, não merece credibilidade.

Conforme já discorrido acima, a versão dos réus, de que foram encontrados entorpecentes apenas em poder do corréu Bruno, restou isolada nos autos, tendo em vista os guardas municipais terem apresentado depoimentos coesos no sentido de que foram encontrados entorpecentes em poder de ambos os réus.

Outrossim, cabe salientar a confissão informal de ambos os acusados aos guardas municipais ainda no local da abordagem (também conforme já exposto acima).

Ademais, a versão do acusado Antônio, no sentido de que as porções de maconha foram encontradas no interior do barraco de madeira e que não sabia da existência delas, não merece ser levada em consideração.

Isto porque, além de não comprovada nos autos, não se revela crível que ele desconhece a existência dos entorpecentes, tendo em vista o fato de ele estar residindo no local há alguns meses (o próprio corréu Antônio afirmou, em juízo, que estava residindo no barraco há dois meses).

Dessa forma, dúvidas não restam de que ambos os acusados estavam comercializando drogas no local da abordagem.

Devidamente caracterizado e comprovado o crime de tráfico de drogas em relação a ambos os réus, e a fim de se dar eficácia ao princípio da individualização da pena, entendo ser o caso de se atribuir a cada acusado os entorpecentes que foram efetivamente encontrados em poder de cada um (corrêu Bruno: 183 porções de crack; corrêu Antônio: 83 porções de maconha), e não de consideração dos entorpecentes em conjunto para ambos.

Assim sendo, com relação ao corrêu Bruno, entendo não ser o caso de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o nítido envolvimento desse acusado em atividade criminosa, que restou evidenciado em razão da apreensão de grande quantidade de drogas (183 porções de crack).

Além disso, levo em consideração o fato de Bruno ter informado, em juízo, que estava morando no local há cerca de três ou quatro meses, de forma que o tráfico de drogas já ocorrida no local há tempo considerável (observando-se nesse ponto, ainda, o relato do guarda municipal Vailson, no sentido de que havia diversas denúncias indicando que o local era utilizado por moradores de rua para a realização de tráfico de drogas).

Nesse particular, consigno que o entendimento da jurisprudência é firme no sentido de a quantidade e variedade de entorpecentes poderem ser utilizadas, dentre outros elementos, como indicativos de envolvimento do agente em atividade criminosa, afastando, por conseguinte, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena em questão.

A propósito, transcrevo ementas de julgados proferidos pelo C. Supremo Tribunal Federal, sempre no sentido de se afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado nas situações acima mencionadas, ante a constatação de dedicação do réu às atividades criminosas:

“Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicção à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Improriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. 1. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pelas instâncias ordinárias não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas. Pelo contrário, apresentaram elas elementos concretos que apontam não só que o paciente atuou conscientemente a rogo de organização criminosa, como também se dedicava à atividade ilícita, ficando demonstrado que ele teria realizado outras viagens em circunstâncias indicativas de transporte de drogas. 2. Tal qual se deu na espécie, “a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14). 3. A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes”. (STF, HC 141292/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Julgado 15/04/2017, Publicado em 22/05/2017)

“Na hipótese, destacou o Tribunal de origem que a quantidade de droga apreendida (3 quilos de cocaína) evidencia o seu grau de envolvimento com o tráfico de drogas, distinguindo-o, portanto, do traficante ocasional. Para efeitos de aplicação da

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006: a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas". (STF, RHC 94.806/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe 16/04/2010)

Ainda no mesmo sentido, ensina Renato Brasileiro de Lima ("Legislação Criminal Especial Comentada", 2ª edição, Editora Jus Podivm, 2014, p. 743/744) que: "Da mesma forma, se o indivíduo for flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado a atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas".

Por outro lado, no tocante ao corréu Antônio, entendo ser possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei em questão, pois presentes todos os seus requisitos: tal acusado é primário e portador de bons antecedentes, conforme FA de fls. 60/61 e certidão de fls. 62/63, e não há prova de que ele se dedicasse a atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa. Razoável se mostra, portanto, a diminuição da pena a ele imposta de 1/2.

Nesse particular, destaco que o Juízo não levará em consideração o fato de Antônio estar respondendo, atualmente, a processo criminal por furto (suspensão, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal), haja vista tal circunstância não caracterizar, tecnicamente, maus antecedentes (cf. art. 64, inc. I, do Código Penal)

Outrossim, uma vez reconhecida a impossibilidade de se levar em consideração, na dosimetria da pena, em duplicidade, os critérios constantes do art. 42, da Lei de Drogas (quantidade e espécie de entorpecentes), sob pena de evidente bis in idem (cf. decidido pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, HCs 112.776/MS, 109.193/MG e 119.976, sendo este último publicado em 18/03/2014, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma), de se consignar que este Juízo os considerará na definição da fração prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), sendo que, na 1ª fase da dosimetria, observará as demais circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal), em especial as condições pessoais do agente (personalidade e conduta social) e as circunstâncias do crime.

Desta forma, no que se refere ao tráfico privilegiado (reconhecido apenas com relação ao corréu Antônio, insta realçar), a fração acima mencionada (intermediária) tem por fundamento a relativa quantidade de entorpecentes efetivamente apreendidos em poder de tal acusado (83 porções), além da sua natureza (maconha - diminuído grau de nocividade em comparação a outros entorpecentes).

No sentido do exposto, ensina Renato Brasileiro de Lima ("Legislação Criminal Especial Anotada", 2ª edição, Editora Jus Podivm, 2014, p. 747) que: "Para fins de determinar o quantum de diminuição da pena, o juiz deve se valer dos critérios constantes do art. 42 da Lei de Drogas - natureza e quantidade da droga, personalidade e conduta social do agente -, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, desde que o faça de maneira fundamentada".

No mais, acerca da alegada dependência química dos réus (tese de autodefesa e, também, da Defesa técnica), entendo que tal restou isolada nos autos (os réus apenas alegaram ser dependentes por ocasião do interrogatório judicial; não houve comprovação documental de internação em clínica pelos acusados). Além disso, mesmo que assim não fosse, decorreria eventual situação de dependência química dos réus não de caso fortuito ou força maior, mas sim de suas próprias voluntariedades, não lhes retirando o entendimento acerca do caráter ilícito do fato.

No sentido do exposto, a jurisprudência é pacífica:

“O juiz não está obrigado a determinar a realização do exame médico se a declaração do réu de que é dependente estiver isolada no conjunto probatório” (TJSP, Ap. Crim. 181.308-3, 2ª Câ. Crim., j. 8-3-1995, rel. Des. Silva Pinto, JTJ 174/333)

“O reconhecimento feito pelo próprio acusado de que é viciado não basta para que o juiz ordene a realização do exame de dependência toxicológica, pois este pode ser dispensado desde que as razões sejam justificadas fundamentadamente, como na hipótese em que inexistente dúvida acerca do poder de autocontrole do agente e a defesa não requereu a perícia durante o curso processual” (TJSP, Rev. Crim. 258.057-3/8-00, 2º Gr. Câ., j. 8-2-2000. rel. Des. Walter Guilherme, RT 777/586).

Ademais, consoante entende o C. Superior Tribunal de Justiça, “se o juiz não detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a instrução processual que justifique a instauração do incidente de sanidade mental, não há necessidade de realização do referido exame” (HC 60.977/ES, 6ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25/10/2011), sendo que “não basta que o acusado se refira à dependência no interrogatório para se tornar necessária a realização do exame de dependência toxicológica. Cabe ao magistrado verificar a real necessidade de sua realização para a formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionariedade regrada, indeferindo a sua realização de forma fundamentada” (HC 51.619, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Medina, j. 09/11/2006), o que é o caso dos autos.

Por fim, afasto, também, a tese da Defesa de desclassificação, para ambos os réus, do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 (porte de drogas para uso pessoal), uma vez que não há nos autos mínimos elementos indicativos da condição de mero usuário dos acusados, sendo que, mesmo que assim não fosse, eventual condição de usuário dos acusados não tem o condão de afastar a de traficante, consoante pacífica jurisprudência. Ao contrário, o conjunto probatório constante dos autos permite a perfeita caracterização do delito previsto no artigo 33, caput, do referido diploma legal, com relação a ambos os réus, pelas razões acima apresentadas.

Destarte, diante das provas carreadas aos autos, impõe-se a condenação de ambos os acusados pela prática do delito de tráfico de drogas, reconhecendo-se, contudo, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) para o corréu Antônio.

Verificadas, assim, materialidade e autoria delitivas, passo, pois, à fixação da pena a ser imposta aos acusados.

Na dosagem da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei de Tóxicos, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado Bruno, tendo vista a grande quantidade de entorpecentes apreendidos em poder dele (183 porções de crack), bem como a natureza dos entorpecentes (alto grau de nocividade do crack). Todavia, tais elementos já foram utilizados para o afastamento do tráfico privilegiado (reduzido), razão pela qual, inexistindo outros elementos, só resta fixar a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, sob pena de “bis in idem”.

No tocante ao corréu Antônio, verifico que o dolo e as demais circunstâncias do crime permaneceram na previsibilidade do tipo legal e nada tiveram de excepcional que autorizassem a exasperação da reprimenda, observando-se que a quantidade e natureza das drogas foram consideradas apenas na fixação da fração do tráfico privilegiado (3ª fase), também sob pena de “bis in idem”. Assim, fixo a pena-base também no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, constato a incidência da atenuante da confissão espontânea no que

concerne ao corréu Bruno (confissão parcial, haja vista ele ter tentado afastar a responsabilização criminal do corréu Antônio). No entanto, consoante o disposto na Súmula 231, do C. Superior Tribunal de Justiça, a pena já foi fixada em seu mínimo legal. Consigno que Bruno é tecnicamente primário, cf. Pesquisa SIVEC de fls. 64, certidão de fls. 65/66 e certidão de fls. 172.

Quanto ao corréu Antônio, não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a serem consideradas, razão pela qual sua pena permanece inalterada (05 anos de reclusão e 500 dias-multa). Não houve confissão da prática do delito por Antônio. Ademais, Antônio é tecnicamente primário, cf. FA de fls. 60/61 e certidão de fls. 62/63.

Finalmente, na terceira fase dosimétrica, realço que o corréu Bruno não faz jus ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pelos motivos supramencionados.

Ainda nesta fase, por outro lado, no que diz respeito ao corréu Antônio, em virtude da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), diminuo a pena de 1/2, pelas razões anteriormente apresentadas, resultando, para este acusado, a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, e 250 dias-multa.

Ausentes demais circunstâncias modificadoras, torno definitivas as penas acima fixadas, quais sejam:

Para o corréu BRUNO: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa; e

Para o corréu ANTÔNIO: 02 anos e 06 meses de reclusão, e 250 dias-multa.

O dia-multa será fixado em seu mínimo legal para ambos os acusados, ante a ausência de informações específicas acerca da situação financeira deles, salvo aquelas genericamente fornecidas por ocasião de seus interrogatórios judiciais, insuficientes para tal finalidade.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixo, para o corréu BRUNO, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, o fechado, em que pese a primariedade técnica deste acusado e o fato de a pena privativa de liberdade a ele imposta não ter ultrapassado 8 anos, tendo em vista a gravidade em concreto da sua conduta (comercialização de grande quantidade de drogas em local amplamente conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico; alto grau de nocividade dos entorpecentes comercializados pelo acusado questão), não desconhecendo este Juízo, todavia, a recente tese de Repercussão Geral fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1052700, de relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, no sentido da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos. Ademais, a fixação de regime inicial mais brando não alcançaria, de forma expressiva, os objetivos de repressão e prevenção visados pelo Direito Penal.

Ainda no tocante ao corréu Bruno, saliento que não se mostra cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, tendo em vista a quantidade de pena a ele aplicada (superior a 04 anos) – art. 44, inc. I, do Código Penal. Ainda, de se observar que tal medida não se mostra socialmente recomendável no presente caso com relação a esse acusado, tendo em vista a sua gravidade em concreto – requisitos subjetivos (art. 44, inc. III, do Código Penal).

No que diz respeito ao corréu ANTÔNIO, fixo, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade deste acusado e a quantidade de pena a ele aplicada.

Ainda com relação ao corréu Antônio, em caráter excepcional, entendo presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, razão pela qual converto a pena privativa de liberdade a ele imposta em duas penas restritivas de direitos, consistentes em

prestação de serviços à comunidade (observando-se o artigo 46, § 3º, do Código Penal) e prestação pecuniária, no valor equivalente a 1,5 salários mínimos (um salário mínimo e meio), a ser destinado a uma entidade pública ou privada com destinação social.

O corréu Bruno não poderá apelar em liberdade, uma vez ainda presentes os requisitos que culminaram com a decretação de sua prisão preventiva. A detração, para fins de eventual progressão (o acusado Bruno se encontra preso preventivamente há, aproximadamente, um mês), deverá ser melhor analisada pelo Juízo das execuções, inclusive em sede de execução provisória, não vislumbrando o Juízo da condenação motivo plausível e evidente para alteração do regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Outrossim, destaco que foi concedida liberdade provisória a Bruno por ocasião da análise do auto de prisão em flagrante (cf. r. decisão de fls. 85/91), tendo tal acusado descumprido as medidas cautelares que foram fixadas, o que ensejou novamente a decretação da sua prisão preventiva às fls. 240/241.

Concedo ao corréu Antônio, lado outro, o direito de apelar em liberdade, haja vista não se fazerem mais presentes as hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva. Levo em consideração, ainda, a fixação do regime inicial aberto e a conversão da pena privativa de liberdade a ele imposta em penas restritivas de direitos (mais adiante, na parte dispositiva da presente sentença, haverá determinação de expedição de alvará de soltura clausulado em favor dele).

ANTE O EXPOSTO, julgo INTEGRALMENTE PROCEDENTES os pedidos acusatórios constantes da ação penal proposta pelo Ministério Público contra ANTÔNIO COSME DE OLIVEIRA NETO e BRUNO MOGHETTI CARVALHO VILIAN e assim o faço para: I - CONDENAR o corréu BRUNO incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, em regime inicial fechado, sem conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, e sem o direito de recorrer em liberdade; e II) CONDENAR o corréu ANTÔNIO como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, e 250 dias-multa, calculada a fração do dia-multa no trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção desde a sua ocorrência, em regime inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em local a ser fixado pelo Juízo da Execução, na forma do artigo 46, § 3º, do Código Penal, e prestação pecuniária, no valor equivalente a 1,5 salários mínimos (um salário mínimo e meio), a ser destinado a uma entidade pública ou privada com destinação social, também a ser designada pelo Juízo da Execução, e com o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o corréu BRUNO na prisão em que se encontra, oficiando-se para tanto.

Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura clausulado em favor do corréu ANTÔNIO.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral para os fins previstos no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).

Os réus estão isentos do pagamento de custas processuais, uma vez que se encontram assistidos por Defensora nomeada em razão do convênio firmando entre a OAB/SP e a DPE/SP (fls. 191), presumindo-se, assim, o estado de miserabilidade de ambos e a impossibilidade financeira de arcarem com tal despesa. Após a confirmação da interposição ou não de recurso, expeça-se certidão de honorários em favor da Defensora nomeada.

P.I.C.

LEONARDO MARZOLA COLOMBINI
- Juiz de Direito -

Atibaia, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA